EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUEM COUBER POR LIVRE DISTRIBUIÇÃO

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica própria e forma Federativa, regulamentado pela Lei nº 8.906/94, com sede em Brasília/DF, no SAUS, Qd. 05, Lote 01, Bloco M, inscrito no CNPJ sob nº 33.205.451/0001-14, por seu Presidente **MARCUS VINÍCIUS FURTADO COELHO,** e por seu advogado que esta subscreve (**Doc. 01**), **vem,** à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 102, I, *a*, e 103, VII, da Constituição, no art. 54, XIV, da Lei nº 8.906/94 e no art. 2º, VII, da Lei nº 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE CAUTELAR

objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 11.051/04 e, por arrastamento, do art. 32 da Lei nº 4.357/64 e do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/09, pelas razões que se passa a expor.

1 - OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS (O COMPLEXO NORMATIVO):

A penalização do contribuinte pela distribuição de lucros e bonificações enquanto em débito com a União Federal foi inicialmente encampada pelo art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, que continha a seguinte redação:

> *"Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:*
> *a) distribuir ...(VETADO)... quaisquer bonificações a seus acionistas;*
> *b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;*
> *c) (VETADO).*
>
> *Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa, reajustável na forma do art. 7º, que será imposta:*
> *a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO)... bonificações ou remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que houverem pago indevidamente;*
> *b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas importâncias."*

Nesse primeiro momento, a proibição de distribuição – com a consequente aplicação de penalidade - se restringia (**a**) às *bonificações* aos acionistas e de (**b**) *lucros* aos sócios-quotistas ou dirigentes. Inexistia – **e continua inexistindo** -, pois, qualquer vedação no dispositivo à plena distribuição de *dividendos* pelas **sociedades anônimas**.

Sobre a inexistência de vedação à distribuição de dividendos, aliás, vale recordar que, quando da edição da Lei nº 4.357/64 houve veto expresso ao vernáculo "dividendos", ocasião em que o Presidente da República à época, em mensagem de veto, manifestou-se no seguinte sentido (**Doc. 02**):

> "*a ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são núcleos propulsores do desenvolvimento nacional",* e, em se tratando de dividendos a sua exclusão do dispositivo precitado se torna ainda mais aconselhável, haja vista que os acionistas minoritários "*ficariam prejudicados por erros de uma administração que, em geral, não teriam forças para substituir*".

Às demais sociedades (que não as SA`s), todavia, (**i**) era **vedada** a distribuição de lucros aos seus sócios quotistas.

Também era vedada a (**ii**) distribuição de lucros aos diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos da empresa quando existente débito em aberto perante a União Federal ou suas autarquias de seguridade social, sendo que, neste caso, a proibição se estendia às SA`s e aos demais tipos societários.

Quase trinta anos após a edição do art. 32 da Lei nº 4.357/64 – e já sob os auspícios da Constituição Federal de 1988 -, novo dispositivo normativo, mais precisamente o art. 52 da Lei nº 8.212/91, foi instituído para limitar a distribuição de bonificações e dividendos. **Agora sim os dividendos aparecem**, especialmente no caso em que o contribuinte possuísse débito junto ao **Instituto Nacional de Seguridade Nacional - INSS**, com a cominação de penalidade equivalente a 50% daquilo que fora distribuído. Confira-se a redação original do dispositivo:

> *"Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:*
> *I – distribuir bonificação ou dividendo a acionista;*
> *II – dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento;*
> *Parágrafo único: A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de 50% (cinquenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento (...)."*

Passados quase quinze anos da edição da norma específica do INSS, mais precisamente em 29 de dezembro de 2004 foi publicada a Lei nº 11.051, que, em seu art. 17, previu a alteração parcial do art. 32 da Lei nº 4.357/64, reavivando esta norma até então em desuso na nova ordem constitucional de 1988:

> *"Art. 17. O art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:*
> *"Art. 32. .....*
> *.....*
> *§ 1º A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:*
> *I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas indevidamente; e*
> *II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas importâncias.*
> *§ 2º A multa referida nos incisos I e II do § 1º deste artigo fica limitada, respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica."*"

Vê-se do dispositivo transcrito que a única alteração introduzida pela Lei nº 11.051/04 ao art. 32 da Lei nº 4.357/64 foi a adição de um § 2º, acarretando a renumeração, como § 1º, do antigo parágrafo único.

O novo parágrafo, por sua vez, atendendo essencialmente a razoabilidade, tão somente limitou a multa prevista no dispositivo originário em no máximo 50% do valor total do débito não garantido.

Mais recentemente, no entanto, a Lei nº 11.941/09 alterou o art. 52 da Lei nº 8.212/91 para harmoniza-la com o art. 32 da Lei nº 4.357/64 – **excluindo, assim, a vedação de distribuição de dividendos nas hipóteses de débitos em aberto com o INSS** - e, de forma expressa, consignou que mesmo nos casos de débitos em aberto junto ao INSS a penalidade será aquela prevista no art. 32 da Lei nº 4.357/64:

> *"Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964.(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)."*

Hoje, portanto, vigente o art. 32 da Lei nº 4.357/64, com as modificações introduzidas pelo art. 17 da Lei nº 11.051/04, e o art. 52 da Lei nº 8.212/91, que se remete integralmente ao dispositivo primeiro mencionado[1].

A norma jurídica que se extrai desses dispositivos, por seu turno, pode ser assim entendida:

> (**i**) penaliza-se as **sociedades anônimas** que distribuírem (**a**) **bonificações** aos acionistas ou (**b**) **lucros** aos integrantes da alta administração, estando em débito com a União Federal ou com o INSS; (**c**) penaliza as **demais sociedades** (exceto as SA`s) **e os seus sócios-quotistas** e integrantes da alta administração que distribuírem/receberem lucros da empresa, quando esta estiver em débito perante a União Federal ou o INSS;
>
> (**ii**) a multa para a pessoa jurídica que incorrer em alguma dessas penalidades será de 50% (cinquenta por cento) do valor distribuído. A multa para os diretores e demais membros da alta administração que receberem remuneração ou bonificação será de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido. Ambas as multas serão limitadas em no máximo 50% (cinquenta por cento) do valor do débito não garantido da pessoa jurídica.

Nesse sentido, em que pese o acréscimo ao § 2º ao art. 32 da Lei nº 4.357/64 ter vindo em favor dos contribuintes – e igualmente a alteração do art. 52 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941/09 -, **ele reacendeu o debate acerca de sua aplicabilidade e constitucionalidade.**

Como se verá doravante, contudo, há de ser reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos em comento com a atual ordem constitu-

[1] Neste ponto, destaque-se que, com a alteração do art. 52 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941/09, remetendo o regramento integralmente ao art. 32 da Lei nº 4.357/64, já não se discute mais a impossibilidade de distribuição de dividendos com débitos tributários ou previdenciários (INSS) em aberto. ***Os dividendos distribuídos pelas SA`s aos acionistas, portanto, hoje, já não geram a penalidade questionada na presente ação***.

cional, especialmente porque: (**i**) afrontam o princípio da livre iniciativa, insculpido nos arts. 1º, inciso IV e 170 da Constituição Federal; (**ii**) malferem o devido processo legal formal e o "*in dubio pro reo*" , previstos no art. 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal; e (**iii**) atentam contra o princípio de proporcionalidade, fundado no "*substantive due process of law*", emanado pelo art. 5ª, inciso LIV da Constituição Federal.

Dessa forma, ante a frontal violação à *"Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos [e] a justiça social"*, cuja defesa incumbe à Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94, art. 44, I), os dispositivos legais acima transcritos suscitam a iniciativa do Conselho Federal da OAB, legitimado universal à propositura da presente ação, ocasião em que se pleiteará que ***seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 11.051/04, que reacendeu a aplicabilidade do art. 32 da Lei nº 4.357/64, com a consequente declaração de inconstitucionalidade por arrastamento deste último dispositivo, bem como do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com redação conferida pela Lei nº 11.941/09***.

2 – DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 11.051/04 E A CONSEQUENTE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 32 DA LEI Nº 4.357/64 E DO ART. 52 DA LEI Nº 8.212/91:

2.1 – A inconstitucionalidade por violação ao princípio da livre iniciativa, insculpido nos arts. 1º, inciso IV e 170 da Constituição Federal

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, ao delimitar os princípios norteadores da nova ordem constitucional que se inaugurava, em seu art.1º, consignou as bases do Estado Democrático de Direito, ocasião em que asseverou que:

> *"Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:*
> *(...)*
>
> *IV* - ***os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa****."*
>
> (grifou-se)

Adensando esse princípio, ao disciplinar especificamente a ordem econômica, a Constituição Federal voltou a prestigiar a livre iniciativa, especialmente através de seu art. 170:

> *"Art. 170. A ordem econômica, fundada na **valorização do trabalho humano e na livre iniciativa**, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:*
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. **É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica**, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."*
>
> (destacou-se)

Sobre o princípio da livre iniciativa, aliás, esse E. Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras oportunidades de se manifestar, exsurgindo de seus julgamentos 03 enunciados de súmula que merecem destaque e que contribuirão para o adequado entendimento da matéria tratada na presente ação:

> Súmula 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimentos como meio coercitivo para a cobrança de tributos.
>
> ***
>
> Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.
>
> ***
>
> Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Todos os 03 enunciados de súmula transcritos prestigiam o princípio da livre iniciativa, externando entendimento solidificado no sentido

de que não se admite sanção política com vistas a promover-se a cobrança de tributos.

Densificando o princípio da livre iniciativa e rechaçando a sanção política para forçar o pagamento de tributos, vale trazer à baila os ensinamentos do E. Ministro Marco Aurélio, externados quando do julgamento do **RE nº 413.782/SC:**

> "Nota-se a tomada de empréstimo de meio coercitivo, objetivando a satisfação de débito tributário. Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da República o procedimento adotado. ***A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal***. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da República, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Repita-se: na dinâmica da própria atividade desenvolvida, fica inviabilizada a atuação, se aquele que a implementa necessita, caso a caso, de recorrer ao fisco, para a obtenção de nota fiscal avulsa. Em Direito, o meio justifica o fim, mas não este, aquele. ***Recorra a Fazenda aos meios adequados à liquidação dos débitos que os contribuintes tenham, abandonando a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, como acaba por ocorrer, levando a empresa ao caos, quando inviabilizada a confecção de blocos de notas fiscais. De há muito, esta Corte pacificou a matéria, retratando o melhor enquadramento constitucional no Verbete nº 547 da Súmula: Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais***."(grifou-se)

Também nesse sentido ***e analisando discussão bastante semelhante a que ora se trava***, no julgamento da **ADI nº 3.453-7,** o Pleno desse E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a inconstitucionalidade de norma que exigia a apresentação pelo contribuinte de certidões de regularidade fiscal para receber valores consubstanciados em precatórios judiciais, enfrentou mais uma vez a questão da sanção política utilizada para pagamento de tributos.

Na oportunidade, sob a relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia, vários Ministros, de forma expressa e veemente, repudiaram esse estratagema. Vale a transcrição de passagens de alguns votos que foram lá colhidos, especialmente por se aplicarem perfeitamente ao caso presente:

> "As formas de obter a Fazenda Pública o que lhe é devido e a constrição da contribuição para o pagamento de eventual débito havido com a Fazenda Pública estão estabelecidas no ordenamento jurídico e não podem ser obtidas por meios que frustrem direitos constitucionais do cidadão" (Ministra Carmem Lúcia)
>
> ***
>
> "A Fazenda Pública possui inúmeros mecanismos destinados à salvaguarda de seus créditos, inclusive com a constrição do patrimônio do devedor e o registro das dívidas em cadastros de inadimplência.
>
> De forma semelhante às tentativas do Fisco de embaraçar a atividade econômica do contribuinte inadimplente, rechaçadas por essa Corte em diversos precedentes (cf., eg., o RE 413.782, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 03.06.2005, e as súmulas 70, 323 e 547 da Corte), a vinculação em exame represente típica hipótese de sanção política, inadmissível no sistema tributário brasileiro." (Ministro Joaquim Barbosa)
>
> ***
>
> "Há, em segundo lugar, aquilo que o eminente advogado da Ordem se referiu, quando aludiu ao parecer do Professor Kiyoshi Harada, ou seja, um caso de abuso legislativo. A norma

> não passa pelo teste da proporcionalidade jurídica. Por quê? Porque tem por finalidade evidente forçar o pagamento de crédito fiscal, mas não é nem necessária, nem adequada a tanto. Não é necessária, pela razão óbvia de que o erário dispõe de modos expeditos de cobranças das execuções fiscais e do próprio recurso da compensação, como tentarei demonstrar um pouco mais adiante, quando falar das dificuldades práticas da obtenção de certidões negativas.
>
> Por outro lado, eu fazia anotações, quando verifiquei que os mesmos argumentos foram levantados com muita precisão na manifestação do **amicus curiae**, ou da **amica curiae**, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, e onde se faz referência expressa à postura permanente desta Corte, objeto das súmulas nºs 70, 323 e 547, que não permitem que o Estado use de meios indiretos para coagir o contribuinte a pagar crédito, até em certos casos, ou, em muitos casos, absolutamente discutíveis: proibição de interdição de estabelecimentos, proibição de apreensão de mercadoria e proibição de aquisição de estampilhas, despachos e até de exercer atividade profissional." (Ministro Cezar Peluso)

Pois bem, o art. 32 da Lei nº 4.357/64, com a redação que lhe foi conferida pelo art. 17 da Lei nº 11.051/04, ao proibir, no caso da existência de débitos em aberto com a União Federal ou INSS, a distribuição: (**i**) de bonificação aos acionistas (SA`s), (**ii**) de participação nos lucros aos sócios quotistas (outras sociedades que não as SA`s) e (**iii**) de participação nos lucros aos demais membros da diretoria e órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos (todos os tipos societários), ***nada mais faz do que utilizar a sanção política como forma de exigir o pagamento do tributo***.

Ou seja, a norma decorrente do art. 32 da Lei nº 4.357/64 (com a redação que lhe foi conferida pelo art. 17 da Lei nº 11.051/04) fere de morte o princípio da livre iniciativa. Bem por isso, fica clara a incompatibilidade desses dispositivos com a atual ordem constitucional, motivo pelo qual há de ser declarada a sua inconstitucionalidade, com a consequente declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 52 da Lei nº 8.212/91.

Há outros argumentos que corroboram essa inconstitucionalidade.

2.2 – A inconstitucionalidade por violação ao Princípio do Devido Processo Legal Formal e do "*In Dubio Pro Reo*"

Ao vedar, sob pena de elevada multa, o pagamento de remuneração e a distribuição de lucros sem que se tenha efetiva certeza da legitimidade dos débitos tributários/previdenciários a que se refere o art. 32 da Lei nº 4.357/64, **o dispositivo desrespeita os princípios do devido processo legal formal e do "*in dubio pro reo*",** previstos respectivamente no art. 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal:

> *"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*
> *(...)*
> *LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;*
> *(...)*
> *LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;"*

Afinal, como é sabido, no caso de eventual decisão administrativa proferida contra os contribuintes, lhes é facultada a possibilidade de se questionar o eventual débito tributário/previdenciário em vias judiciais.

No ínterim procedimental normal das cobranças tributárias, como é de conhecimento geral, uma vez finalizado o contencioso administrativo desfavoravelmente ao contribuinte e definitivamente constituído o crédito tributário, é dever da Administração Pública a inscrição do débito em dívida ativa, possibilitando o ajuizamento de Execução Fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/80.

Ajuizado o feito executivo, o contribuinte será citado para, em até 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir o débito (art.8º[2] da Lei nº 6.830/80). Somente após essa garantia poderá apresentar Embargos à Execu-

[2] Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

ção Fiscal, ação de conhecimento apta a desconstituir a presunção relativa de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

Ocorre que, entre a finalização do procedimento administrativo e o efetivo ajuizamento da Execução Fiscal, em regra, transcorre-se prazo absolutamente elevado, valendo relembrar que o prazo de prescrição para o fisco ajuizar o feito executivo é de até 05 anos (art. 174[3] do CTN).

Ou seja, entre a finalização do procedimento administrativo e o efetivo ajuizamento da Execução Fiscal o contribuinte estará à mercê da Administração Pública, período durante o qual, ao teor do art. 32 da Lei nº 4.357/64, não poderá pagar bonificações ou distribuir lucros, sob pena de lhe ser aplicada penalidade.

Essa limitação, porém, é absolutamente irrazoável, seja porque imputada à mora da própria Administração Pública com o ajuizamento da Execução Fiscal, seja porque a própria legislação federal – Lei nº 6.830/80, por exemplo – permite que o contribuinte discuta judicialmente a legitimidade do débito executado.

Portanto, **a se prevalecer a regra contida no art. 32 da Lei nº 4.357/64, em verdade, se estaria criando verdadeira norma de exceção, impedindo o contribuinte de exercer a contento sua atividade empresarial, a despeito de não se ter finalizado o devido processo legal** – em alguns casos, aliás, como aqueles de mora da Administração Pública no ajuizamento da ação, ele não terá sequer começado. Seria, assim, nefasto exemplo de superação injustificada do princípio do "*indubio pro reu*", corolário do Estado Democrático de Direito.

Vale lembrar, ainda, que a Administração Pública dispõe de forma específica e mais benéfica para a cobrança de seus créditos, regulamentada na já citada Lei nº 6.830/80.

Essa norma, naturalmente, para além de garantir plena percepção estatal dos valores executados é, ainda, instrumento de garantia dos contribuintes de que lhes será oportunizada a ampla defesa e o contraditório antes de serem constritos os seus bens.

[3] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Justamente por isso é que esse E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em mais de uma oportunidade, no sentido de que, em tendo a Fazenda Pública meio próprio de cobrar tributos, deve o mesmo ser observado, sob pena de mitigação ao contraditório e a ampla defesa dos contribuintes. Nesse sentido, veja-se manifestações colhidas quando do julgamento do **RE nº 413.782/SC:**

> "A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.
>
> (...)
>
> O objetivo é único, é um meio coercitivo para recolhimento do débito e, para chegar-se ao recolhimento, temos o judiciário, o executivo fiscal" (Ministro Marco Aurélio)
>
> ***
>
> "Senhor Presidente, como já me manifestei inicialmente, não entraria nessa discussão ou na tecnicalidade do tributo. A mim, afigura-se bastante e suficiente a consideração de que ***o Estado, como demonstrou o Ministro Marco Aurélio, dispõe de meios outros para efetuar a cobrança*** e de que a fórmula adotada pelo Estado, a meu ver, não passa no teste da proporcionalidade." (Ministro Gilmar Mendes)
>
> ***
>
> "A circunstância **de não se revelarem absolutos** os direitos e garantias individuais proclamados no texto constitucional **não significa** que a Administração Tributária possa **frustrar** o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, **impondo-lhe** exigências gravosas, que, **não obstante** as prerrogativas extraordinárias (**já**) garantem o crédito tributário, **visem**, em última análise, **a constranger** o devedor a sa-

tisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam" (Ministro Celso de Mello)

Também por esse motivo deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 11.051/04, o qual reavivou o art. 32 da Lei nº 4.357/64, com a consequente declaração de inconstitucionalidade tanto desses dispositivos quanto, por arrastamento, do art. 52 da Lei nº 8.212/91.

2.3 – A inconstitucionalidade por violação princípio de proporcionalidade, fundado no "*substantive due process of law*", emanado pelo art. 5ª, inciso LIV da Constituição Federal.

Sobre as duas vertentes do princípio do devido processo legal insculpido no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, já transcrito alhures, manifestou-se com propriedade e objetividade o Ex-ministro desse E. Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Velloso, notadamente quando do julgamento da **ADI 1.511-MC** (DJ 06/06/03):

> *"Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 consagra o devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e processual, nos incisos LIV e LV, do art. 5º, respectivamente. (...)* **Due process of law, *com conteúdo substantivo* — substantive due process — *constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade (*reasonableness*) e de racionalidade (*rationality*), devem guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir***. *Paralelamente*, due process of law, *com caráter processual* — procedural due process — *garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa."*
>
> (grifou-se)

No presente tópico, portanto, será abordado o devido processo legal em seu conteúdo substantivo, especialmente para se demonstrar que a norma decorrente do art. 32 da Lei nº 4.357/64 **não** escapa ao teste da razoabilidade/proporcionalidade.

Sobre o princípio da Proporcionalidade, notadamente no que toca às suas vertentes de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, já se manifestou em obra doutrinária o Exmo. Ministro Gilmar Mendes:

> *"**A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade**.*
> *Essa nova orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit). Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da medida há de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade ou razoabilidade em sentido estrito).*
> *O pressuposto da **adequação** (Geeignetheit) **exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos**. O requisito da **necessidade** ou da exigibilidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) **significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos**. Assim, apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado."*[4]
>
> (destacou-se)

Dessa forma, atualmente, para que uma norma jurídica seja válida não basta que ela se sujeite tão somente à reserva da legalidade, ela de-

[4] Mendes, Gilmar Ferreira. A Proporcionalidade na Jurisprudência do STF. Daqui extraído: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6UMSeLTj9BIJ:www.gilmarmendes.org.br/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D114:a-proporcionalidade-na-jurisprudencia-do-supremo-tribunal-federal%26id%3D3:controle-concreto-de-normas%26Itemid%3D74+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

verá, ainda, demonstrar-se proporcional, percorrendo o caminho da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Analisando objetivamente a norma decorrente do art. 32 da Lei nº 4.357/64 vê-se, no entanto, que ela **não** passa no teste da proporcionalidade.

Isso porque ainda que ela possa ser considerada norma adequada para maximizar o pagamento de débitos tributários, ela claramente não é necessária. Ou seja, dentre os meios possíveis para atingimento de determinado fim ela não é a menos prejudicial, tampouco é proporcional em sentido estrito, noutros termos, o mal que ela ocasiona não é proporcional ao bem que ela pretende garantir.

Além de ser um meio inapropriado, *data venia*, a norma em questão é um instrumento mais danoso e ineficiente que todos os demais meios disponíveis para a cobrança ou garantia de débitos tributários/previdenciários federais, a saber: (**i**) a Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80); (**ii**) a Ação Cautelar Fiscal (Lei nº 8.397/92); (**iii**) a fraude à Execução Fiscal (arts. 184 e 185 do CTN); (**iv**) a penhora *online*; (**v**) o arrolamento para acompanhamento do patrimônio do contribuinte em débito (art. 64 da Lei nº 9.532/97). ***Esse fato, pois, já demonstra a desnecessidade da norma.***

Também não se vislumbra a proporcionalidade em sentido estrito no caso em destaque. Afinal, como já decidiu esse E. Supremo Tribunal Federal mais de uma vez, **não se pode mitigar a livre iniciativa do contribuinte para pressionar o pagamento de tributos.** A sanção política não se presta à coação para pagamento de tributos.

Esse é o racional que se depreende dos enunciados de súmula do STF nºs 70; 323 e 547, já transcritos nesta peça.

Aliás, o pleno desse E. Supremo Tribunal Federal, analisando a constitucionalidade de normas que exigia que o contribuinte não tivesse débitos em aberto para poder receber os valores expressos em precatórios judiciais, com base na desproporcionalidade, concluiu pela inconstitucionalidade da norma.

O raciocínio desenvolvido no julgamento da **ADI nº 3.453-7** aplica-se integralmente ao caso presente, sendo precisas as palavras que lá foram cunhadas pelo E. Ministro Cezar Peluso:

> "Finalmente, a norma desarrazoada do ponto de vista prático. Por quê? Porque todos conhecemos, isso é fato público e notório, que a obtenção de certidão negativa, não em todas as esferas, mas, sem dúvida nenhuma, em algumas delas, e a norma não abre nenhuma exceção, abrange todas, há dificuldades de ordem prática em obter a certidão.
>
> Aproveito a oportunidade para fazer menção a um caso concreto em que tive necessidade de obter certidão para fazer um negócio jurídico. ***Constava, na Receita Federal, a seguinte notícia no "site": a situação atual do contribuinte não permite reconhecer-lhe plena regularidade***.
>
> Eu que tenho o imposto recolhido compulsoriamente na fonte pensei: o que terá acontecido com o Tribunal de Justiça de São Paulo ou com o Supremo Tribunal Federal que não recolheram o imposto de renda devido? Fui ver do que se tratava. ***Era diferença de SELIC, no tempo em que isso ainda era calculado pelo contribuinte, de zero vírgula não sei quantos centavos, que, naquela data, depois de não sei quantos anos, dava quatro reais e alguma coisa. Eu não ia conseguir obter certidão sem demonstrar que não estava devendo***. Isso, sem contar – e também é fato conhecido – que, em outras esferas, para se obter certidão, por exemplo, de prefeitura, o cidadão tem de levantar no arquivo do avô todos os carnês pagos, se não, não sairá com menos de cento e vinte dias. Isso é uma dificuldade concreta, perante a qual o intérprete do direito não pode fechar os olhos.
>
> Eventual certidão erigiria, quando positiva, mera presunção de dívida, se estivesse inscrita. ***Ora, uma vez inscrita a dívida, a obrigação do órgão público é promover imediatamente a execução fiscal. E está aí o modo adequado até para paralisar a cobrança do crédito do precatório, bastando ao órgão público que promova a penhora desse mesmo crédito. <u>É, muito simples, inscrita a dívida, executa e penhora o crédito, não</u>***

<u>havendo necessidade doutro expediente</u>. O que demonstra, mais uma vez a meu juízo, que tem toda razão a eminente Ministra-Relatora e os demais Ministros que a acompanharam, em não deixarem de ver aqui ofensa a múltiplas normas e princípios constitucionais."

(grifou-se)

Também nesse prisma, se manifestou o E. Ministro Celso de Mello no julgamento do **RE nº 402.769/RS,** como se nota de sua ementa:

"SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. ***INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO****, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO "SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW". IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR - QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - "NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR" (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132).* ***A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO "ESTA-***

***TUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE"**. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO"*

(destacou-se)

É tão ululante a desproporcionalidade da norma em comento que não é difícil imaginar, se eventualmente ela for validada por esse E. Tribunal Constitucional – o que se admite tão somente em reverência ao principio da eventualidade -, que incentivará os demais entes federativos – mais de 5.000 Municípios e 27 Estados – a adotarem regras semelhantes, o que tornaria inviável a vida empresarial no Brasil.

Chegar-se-ia ao absurdo da pessoa jurídica ter que consultar milhares de entes para verificar a possibilidade de distribuir bonificações ou lucros aos sócios quotistas. Essa burocracia, em última análise, representaria restrição intransponível para as empresa, ensejando na morte e sepultamento dos institutos. Nada mais irrazoável, portanto.

Com efeito, também sob o viés da proporcionalidade, deve ser declarada a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 11.051/04, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 32 da Lei nº 4.357/64 e do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/09.

3 - DO PEDIDO CAUTELAR:

Como se sabe, os artigos 10 e 11, da Lei n. 9.868, de 1999, permite a **concessão de liminar** em Ação Direta de inconstitucionalidade, tendo a doutrina afiançado tratar-se de medida que visa a antecipar os efeitos de eventual decretação de inconstitucionalidade ao final do processo[5], cujos requisitos para concessão da medida são os tradicionais: i) *fumus boni iuris* e ii) *periculum in mora*.

Ambos estão presentes no caso concreto.

É que o dispositivo ora impugnado, ao apresentar total contrariedade ao apresentar contrariedade ao texto constitucional, conforme demons-

[5] **Teori Zavascki**, Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 61/64.

trado acima, deve ser imediatamente afastado do ordenamento jurídico pátrio, eis que nulo.

Como leciona o Professor e hoje Ministro desse E. Tribunal, Luís Roberto Barroso[6]:

> *"(...)*
> *Nenhum ato legislativo contrário à Constituição pode ser válido. E a falta de validade traz como consequência a nulidade ou a anulabilidade. No caso da lei inconstitucional, aplica-se a sanção mais grave, que é a de nulidade. Ato inconstitucional é ato nulo de pleno direito.*
> *(...)"*

Nesse sentido, sobejamente demonstrados os requisitos autorizadores para deferimento de cautelar.

Evidente o *fumus boni juris*, pois os dispositivos guerreados desnaturam a proteção constitucional dada aos contribuintes. É dizer, **viola:** (**i**) o princípio da livre iniciativa, insculpido nos arts. 1º, inciso IV e 170 da Constituição Federal; (**ii**) o devido processo legal formal e o "*in dubio pro reo*" , previstos no art. 5º, incisos LIV e LVII da Constituição Federal; (**iii**) o princípio de proporcionalidade, fundado no "*substantive due process of law*", emanado pelo art. 5ª, inciso LIV da Constituição Federal..

Vale lembrar, no particular, excerto de obra da Ministra Cármem Lúcia, para quem:

> *"... as conquistas relativas aos direitos fundamentais não podem ser destruídas, anuladas ou combalidas, por se cuidarem de avanços de toda a humanidade, e não dádivas estatais que pudessem ser retiradas segundo opiniões de momento ou eventuais maiorias parlamentares."*

No que concerne ao *periculum in mora* é preciso perceber que a cada dia em que se perpetua o estado de inconstitucionalidade ocasionado pela lei ora impugnada maiores são os prejuízos aos contribuintes, que ficam limi-

[6] BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2006. p. 15

tados à distribuírem bonificações e participação nos lucros. Prejudicando as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que deixam de recebê-los.

Diante do exposto, **requer o Conselho Federal da OAB a imediata suspensão da aplicação do art. 32 da Lei nº 4.357/64, cuja redação foi parcialmente modificada pelo art. 17 da Lei nº 11.051/04, bem assim do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.941/09** – antes da audiência da Presidência da República e do Congresso Nacional, bem como da manifestação da AGU e da PGR, por decisão monocrática, *ad referendum* do Plenário[7], ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta**.**

4 - DO PEDIDO FINAL:

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil **requer**:

a) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99 e antes da audiência da Presidência da República e do Congresso Nacional, bem como da manifestação da AGU e da PGR, por decisão monocrática, *ad referendum* do Plenário[8], ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta, para que seja determinada **imediata suspensão da aplicação do art. 32 da Lei nº 4.357/64, com redação parcialmente modificada pelo art. 17 da Lei nº 11.051/04, bem assim do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.941/09;**

b) a notificação da **PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,** da **CÂMARA DOS DEPUTADOS,** e do **SENADO FEDERAL,** por intermédio de seus Presidentes, para que, como responsáveis pela elaboração das normas impugnadas, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

c) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre o mérito da presente ação;

d) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

[7] Exemplo recente deste procedimento é a ADI nº 4.917/DF (DJe 21.03.2013).
[8] Exemplo recente deste procedimento é a ADI nº 4.917/DF (DJe 21.03.2013).

e) pede-se, por último, a procedência desta Ação Direta de Inconstitucionalidade **para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 11.051/04, que alterou parcialmente o art. 32 da Lei nº 4.357/64 e, por sua vez, a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 52 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/09;**

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 05 de setembro de 2014.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente do Conselho Federal da OAB
OAB/PI 2525 – OAB/DF 18.958

Luiz Gustavo A. S. Bichara
Procurador Especial Tributário do Conselho Federal da OAB
OAB/RJ 112.310

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior
OAB/DF 16.275